Tópico 07

Administração e Aspectos Legais

DIREITO EMPRESARIAL I

1. Introdução

Você já deve ter reparado que o Direito está sempre presente no nosso cotidiano. Ainda que não sejamos operadores do Direito e que nossas atividades pessoais e profissionais nada tenham a ver com a área, ele está sempre ali, à espreita, influenciando nas relações travadas na soci e.

O Direito interfere nas mais diversas searas de nossas vidas! Quer alguns exemplos? Vamos lá!

Vai se casar? Vai comprar uma casa, um carro? Quer fazer um empréstimo no banco? Precisou de um medicamento no SUS e não conseguiu? Comprou um produto que veio com defeito? Quer contratar um trabalhador doméstico? **Quer abrir uma empresa?**

Em todas essas situações, o Direito se faz presente, afinal de contas, ele serve para regular as relações sociais, trazendo – ou, ao menos, tentando trazer – paz para a sociedade.

Em nossa lição, vamos ingressar no universo do Direito Empresarial, esse ramo do Direito que se ocupa de regulamentar as relações empresariais, sejam elas desenvolvidas de forma individual ou em sociedades. No futuro, tais conhecimentos poderão ser decisivos no desempenho de sua atividade profissional. Afinal de contas, são diversas as profissões que se correlacionam com a atividade empresarial. Quer ver? Acompanhe o desenvolvimento da lição e descubra como o Direito

Comercial/Empresarial está intrinsecamente ligado à Economia e ao desenvolvimento das sociedades ao longo da História.

2. Desenvolvimento histórico do direito empresarial

O que mais me encanta no Direito é observar sua relação com a História. Contar a história do desenvolvimento de um ramo específico do Direito é também contar a história do desenvolvimento da(s) sociedade(s). É contar como as relações se trava(va)m e quais as soluções foram/são buscadas para resolver os conflitos de interesse derivados dessas interações.

Quando falamos de Direito Comercial/Empresarial, estamos falando do ramo do Direito responsável por dar conta das trocas de mercadorias, das compras e vendas de produtos, da produção em pequena, média ou larga escala. Estamos falando do mercadinho da esquina de casa, mas também dos grandes conglomerados transnacionais. Estamos nos referindo àquela vizinha que vende bolo de pote para complementar a renda, mas também ao dono da frota de ônibus da cidade.

Segundo o doutrinador Fábio Ulhoa Coelho (2016, p. 12):

> *"O Direito Comercial cuida do exercício dessa atividade econômica organizada de fornecimento de bens ou serviços, denominada empresa. Seu objeto é o estudo dos meios socialmente estruturados de superação dos conflitos de interesses envolvendo empresários ou relacionados às empresas que eles exploram. As leis ea forma pela qual são interpretadas pela jurisprudência e doutrina, os valores prestigiados pela sociedade, bem assim o funcionamento dos aparatosestatal e paraestatal, na superação desses conflitos de interesses, formam o objeto dadisciplina".*

Esse ramo específico do Direito foi se desenvolvendo conforme a economia ia se desenvolvendo. Podemos considerar que ele nasce quando nasce a ideia de troca de mercadorias excedentes, lá na Idade Média, dentro da estrutura feudal.

Costumamos dividir o desenvolvimento histórico do Direito Comercial/Empresarial (a seguir explicaremos o porquê das duas nomenclaturas) em fases. Tais fases se correlacionam com o desenvolvimento do comércio e da economia europeia e, posteriormente, mundial.

2.1) FASE PRIMITIVA

A fase primitiva, também chamada de período pré-comercial, retrata o momento anterior ao surgimento do Direito Comercial. Nesse momento histórico, ainda não havia surgido a ideia de comércio, pelo menos, não da forma como a conhecemos desde a Idade Média. Essa fase primitiva nasce na Antiguidade e perdura até o surgimento da moeda.

Nesse período, de economia predominantemente rural, os donos de terra produziam os bens necessários à sua subsistência e de sua família em suas próprias terras. Assim, dentro daquela propriedade, a princípio, tinha-se tudo para a subsistência de seus habitantes. O que não se tinha naquela estrutura era adquirido através das trocas de mercadorias.



No sistema de trocas, não se utiliza dinheiro, cada um oferece a mercadoria que tem em troca da mercadoria do outro. O valor – por quantas batatas se trocaria uma penca de bananas – é negociado entre as partes.

Então, se em minhas terras eu produzia um excedente de soja, mas não produzia café, realizava a troca do meu excedente de soja pelo excedente de café de outro produtor.

Uma figura muito importante surgida nesta época é a figura do mascate. O mascate era aquele que realizada o escambo (troca) entre os produtores. Por exemplo: o mascate que produzia farinha, viajava trocando farinha por arroz, por gado, por trigo, produzidos em outros locais.

Com o passar do tempo, o escambo passou a não mais atender às necessidades dos envolvidos nas trocas. Imagine o seguinte cenário: você produziu 50 sacas de trigo, mas só precisa de 10. Portanto, você tem 40 sacas para trocar. Seu mascate visita os vizinhos, a fim de trocar as 40 sacas de trigo por milho, soja, arroz, gado e outros produtos necessários. Mas, o produtor de milho não tem interesse em trigo, pois ainda tem bastante em estoque. Logo, a troca fica inviabilizada, pois o produtor daquilo que você necessita não está interessado no seu produto. Como resolver? É nesse momento que se cria a moeda.

A moeda passa a ser a forma de se trocar as mercadorias. O mascate não vai mais oferecer as sacas de trigo em troca das sacas de milho. Ele vai dizer quantas moedas vale cada saca de trigo. E, assim, quem se interessar, não precisa necessariamente ter o produto que ele queria. Se o produtor de arroz se interessa por adquirir trigo, ele paga com moeda e, então, o produtor de trigo pode adquirir o milho que lhe interessa.

É neste momento, com o surgimento da moeda, que se passa a ter a **ideia primitiva de comércio**.

2.2) FASE SUBJETIVA

Essa ideia primitiva de comércio vai perdurar até a Idade Média. Muito embora antes desse período histórico exista algum tipo de legislação aplicável às relações comerciais, é durante a Idade Média que há os primeiros regramentos esparsos.

Surgem nesta época as **corporações de ofício**. O que são essas corporações? São espécies de organizações de produtores de mercadorias, as quais “gozavam de significativa autonomia em face do poder real e dos senhores feudais” (COELHO, 2016, p.13) e pretendiam proteger e regulamentar, ainda que de forma rudimentar, as atividades desenvolvidas por seus membros.

O surgimento das corporações de ofício está diretamente ligado ao desenvolvimento da ideia de comércio, ideia essa que, como vimos, se dá em virtude da criação da moeda.

Outro fator que contribuiu fundamentalmente para o desenvolvimento do comércio é a modernização das atividades. Um bom exemplo é a modernização do arado e a implementação do uso de moinhos. Tais instrumentos permitiram o aumento exponencial da produção, gerando, em consequência, um excedente muito maior, movimentando o comércio entre os feudos.

Com o aquecimento dessa atividade, surgem as **feiras mercantis.** A partir de então, diminui-se o papel do mascate, já que a compra e a venda de mercadorias passam a ser realizadas em um lugar fixo, as feiras. É em torno dessas feiras que surgirão, mais à frente, as cidades.

As feiras mercantis causaram a diminuição da importância dos mascates e foram também as responsáveis pelo surgimento das cidades.

Então, na Idade Média, tem-se a criação de feiras mercantis, que darão lugar às cidades, e a criação das corporações de ofício, responsáveis pelas primeiras normas aplicáveis ao comércio.

Tais normas valem apenas para os membros das corporações. É por isso que essa primeira fase do Direito Comercial é chamada de fase subjetiva, pois o foco do regramento é a pessoa que desenvolve a atividade, ou seja, o comerciante.

Considerava-se comerciante a pessoa que cumprisse os requisitos formais para inscrever-se nas corporações. Então, para gozar da proteção legal, o comerciante deveria cumprir certas normas, tornando-se membro da corporação.



Podemos traçar um paralelo com o que ocorre, hoje, com advogados, por exemplo. Quem é considerado advogado? A pessoa que tenha concluído o curso de Bacharelado em Direito, que tenha sido aprovada no Exame de Ordem da OAB e que tenha sua inscrição deferida, após apresentar toda a documentação solicitada e a análise desta ter sido positiva. O status de advogado independe do efetivo exercício da profissão, assim como o status de comerciante independia do efetivo exercício, bastando a inscrição nas corporações. A contrário senso, a pessoa que desenvolvesse a atividade comercial e não se inscrevesse nas corporações não era considerada comerciante. Essa condição também não era herdada; morrendo o comerciante, morria a atividade.

Pode parecer óbvio considerar comerciante aquele que se inscrevesse nas corporações, mas essas legislações se mostraram insuficientes para abarcar o universo do comércio, haja vista que elas não se preocupavam em proteger a

atividade, mas tão somente o sujeito que a desenvolvia.

Há um marco histórico que evidencia a limitação dessa fase subjetiva, gerando a necessidade de se desenvolver uma nova teoria. São Grandes Navegações (século XV – início do século XVII).

A expansão do comércio causado pelas Grandes Navegações ocasionou a necessidade de se repensar o Direito Comercial focado tão somente na figura do comerciante.

A expansão comercial europeia deixa claro que a atividade comercial pode ir muito além das feiras mercantis e que manter todo o foco da legislação apenas na figura do comerciante não dará conta deste novo momento que se vivencia. Com o comércio além-mar e o próprio comércio gerado para possibilitar essa atividade (produção de embarcações, por exemplo), muda-se a essência. O comerciante deixa de ser o mais importante, passando a ser cerne da legislação o próprio **comércio**, a atividade desenvolvida.

2.3) FASE OBJETIVA

Essa fase, na qual o comércio passa a ser o foco da legislação, é conhecida como fase objetiva ou segunda fase do Direito Comercial.

Se a importância de se superar a fase subjetiva aparece com as Grandes Navegações, o marco histórico dessa mudança apenas surge na França de Napoleão. É tão somente no início do século XIX que surge uma teoria, futuramente transformada em legislação, para regulamentar de modo diverso o Direito Comercial. Esta teoria é conhecida como Teoria dos Atos de Comércio.

A partir deste momento, passam a ser regidas pelo Direito Comercial todas as atividades consideradas de mercancia. Nesta fase, o Direito Comercial "não mais se considera o direito de alguns sujeitos (os comerciantes), mas a disciplina jurídica de determinados atos (os atos de comércio)" (COELHO, 2016, p. 13).

Ainda assim, é importante mencionar que a teoria dos atos de comércio não abarca todas as atividades mercantis. As atividades tipicamente desenvolvidas pela aristocracia não ganham a proteção legal. Por que? Porque a teoria e a legislação correspondente surgem no momento pós-Revolução Francesa (1789), ou seja, momento no qual a burguesia toma o poder dos aristocratas e busca atender apenas aos seus próprios interesses. Assim, não são consideradas atos de comércio as atividades ligadas à terra e prestação de serviços.

A legislação com foco na atividade comercial funciona muito bem por um bom período de tempo, mas, como é comum à História, novos acontecimentos a tornam incompleta. O marco histórico da vez é a **Revolução Industrial** (1820-1840).

A Revolução Industrial moderniza as relações comerciais, tornando-as muito mais complexas do que até então imaginado. O foco apenas nas relações de compra e venda de mercadorias se mostra insuficiente para dar conta das novas configurações advindas do complexo sistema industrial, o que, futuramente, dará lugar à terceira fase do Direito Comercial.

2.4) FASE SUBJETIVA MODERNA OU EMPRESARIAL

Apesar de ser a Revolução Industrial a responsável por demonstrar a necessidade de

se superar a teoria dos atos de comércio, é apenas na Itália do século XX que surge uma teoria substitutiva e uma legislação correspondente.

O Código Civil italiano de 1942 traz à luz a Teoria da Empresa, a partir da qual

o Direito Comercial passa a ser um ramo do Direito responsável pela regulamentação de uma forma específica de produção e circulação de mercadorias, a forma empresarial.

O enfoque da disciplina, a partir de então, não é na atividade de comércio, nem tampouco no comerciante, mas na **atividade empresarial**.

> *"Essa teoria, cujo maior expoente é o italiano Asquini, propõe a superação da vinculação entre sujeito e objeto do direito comercial, pois é possível que o objeto (empresa) sobreviva independentemente do destino do sujeito (empresário). Para o autor, a proteção do direito comercial deve recair mormente sobre a empresa, que significa atividade empresarial, com fim lucrativo, organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Nesse passo, o que deve ser preservado, como importante instrumento de desenvolvimento de um Estado, é a empresa. Por sua vez, essa fase possui conteúdo subjetivo, pois a legislação regula a atividade (a empresa), mas incide sobre o sujeito (empresário). Eis o porquê da denominação fase subjetiva moderna" (CHAGAS, 2017, p. 45, adaptado).*

Portanto, a Teoria da Empresa ocupa-se da atividade desenvolvida, mas esta atividade tem seu objeto ampliado, não se resumindo àquelas caracterizadas como atos de comércio. Além disso, volta-se novamente o olhar para quem desenvolve a atividade, o empresário, pois, como veremos, é ele quem efetivamente exerce a empresa.

É em virtude desta mudança que o ramo do Direito passa a ser conhecido como Direito Empresarial, considerando-se ultrapassada a denominação Direito Comercial.

Vamos cuidar especificamente do conceito de empresário, mas, antes disso, vamos estabelecer mais algumas diferenças entre a Teoria dos Atos de Comércio e a Teoria da Empresa.

3. Atos de comércio e teoria da empresa

Como vimos, a Teoria dos Atos de Comércio lida apenas com as atividades consideradas de mercancia, ou seja, compra e venda de mercadorias. Ficaram de fora as atividades ligadas à terra e a prestação de serviços. Também não havia uma grande preocupação com as atividades de produção de bens, focando-se mesmo na sua comercialização.

No Brasil, o Regulamento 737 de 1850, responsável por regulamentar o Código Comercial de 1850, definia que eram considerados atos de comércio no Brasil:

> *Art. 19. Considera-se mercancia:*
>
> *§ 1º a compra e venda ou troca de efeitos móveis ou semoventes, para os vender por grosso ou a retalho, na mesma espécie ou manufaturados, ou para alugar o seu uso;*
> *§ 2º as operações de câmbio, banco e corretagem;*
> *§ 3º as empresas de fábricas, de comissões, de depósito, de expedição, consignação e transporte de mercadorias, de espetáculos públicos;*
> *§ 4º os seguros, fretamentos, riscos e quaisquer contratos relativos ao comércio marítimo; e*
> *§ 5º a armação e expedição de navios.*
>
> *(BRASIL, 1850)*

Vê-se que, no Brasil, ampliou-se já em 1850 os atos considerados de mercancia, envolvendo até mesmo algumas operações financeiras. Todavia, já dissemos que esta

teoria se mostrou insuficiente perante a complexidade que as relações comerciais passaram a ter pós-Revolução Industrial.

> *"Neste contexto, seguindo uma tendência europeia, os juristas chamavam a importância de se abandonar o critério objetivo, ou seja, que atentasse para o objeto da atividade mercantil, o ato de comércio (mormente em face da limitação oferecida pelo artigo 19 do Regulamento 737/1850), e passar-se a um critério subjetivo, isto é, que se considera o sujeito da atividade mercantil, assimilando o fenômeno das empresas, cuja importância para a economia era inequívoca. Dessa forma, criou-se a necessidade de se estabelecer um tratamento jurídico específico para a empresa, considerada como forma organizada de atuação econômica visando a produção de riquezas" (MAMEDE, 2018, p. 55).*

Assim, a Teoria dos Atos de Comércio é superada, ganhando espaço a Teoria da Empresa. Entende-se que empresa é uma atividade muito mais ampla do que comércio, é por isso que a Teoria da Empresa vem aprimorar a Teoria dos Atos de Comércio.

Você já ouviu falar da Teoria da Firma, de Ronald Coase? A teoria do economista inglês em muito se correlaciona com a Teoria da Empresa, na medida em que Coase tenta explicar a necessidade da "firma" (expressão não usual atualmente) para a redução dos custos de mercado.

Saiba mais através da leitura destes dois artigos:

Teoria da Firma: uma relação entre a empresa e o mercado

Clique aqui

Ronald Coase, Nobel de Economia em 1991; conheça seu legado

Clique aqui

A fim de superar o embate entre a primeira e a segunda fases do Direito Comercial (fase subjetiva e fase objetiva), a Teoria da Empresa, do italiano Alberto Asquini, conceitua a empresa como um fenômeno poliédrico, ou seja, o conceito de Empresa não é único, existindo vários perfis da empresa.

Tais perfis foram resumidos na tabela seguinte:

Tabela 1	Perfis da Empresa segundo a Teoria da Empresa de Alberto Asquini
Subjetivo	Empresa como sinônimo de empresário. Foco no sujeito que desenvolve a atividade empresarial. Modernamente, esse sujeito não costuma ser a

	pessoa física, mas, na maioria das vezes, a pessoa jurídica. Assemelha-se à Primeira Fase do Direito Comercial.
Funcional	Empresa é considerada a atividade empreendedora determinada a um certo objetivo. Assemelha-se à Segunda Fase do Direito Comercial, porém, ampliada, de modo que não é apenas a atividade mercantil (compra e venda) que se considera atividade empresarial.
Objetivo	Empresa é o complexo patrimonial (complexo de bens necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial). Esse perfil deixa de lado, por exemplo, as atividades empresariais desenvolvidas por meio da Internet, na medida em que considera empresa o local físico de desenvolvimento da atividade.
Corporativo	Empresa é a junção dos três aspectos anteriores. É todo o complexo de pessoas, atividades e bens necessários ao desenvolvimento da atividade empresarial.

A Teoria da Empresa permanece atual, pois não se limita a caracterizar apenas um aspecto da atividade como sendo o responsável por definir a empresa como empresa. A grande sacada de Alberto Asquini foi criar uma teoria que abarca todas as vertentes da atividade empresarial. É por isso que ela se mantém, tendo sido adotada, inclusive, pelo nosso Código Civil de 2002.

4. Fontes do direito empresarial

No Direito, chamamos de fonte tudo aquilo que direciona a elaboração e a aplicação das normas jurídicas. Assim, são fontes do Direito, a Constituição Federal, as leis, os tratados internacionais, os decretos e regulamentos. Mas, também, os costumes, os princípios gerais de Direito, a doutrina e a jurisprudência.

Os primeiros constituem as fontes formais do Direito, enquanto os segundos constituem as fontes materiais. Essas fontes se influenciam mutuamente e são interdependentes umas das outras.

Podemos traçar um paralelo entres as fontes do Direito com as nascentes de água. Fonte é onde se origina algo, é o início, o nascedouro. Quer seja de um ramo do Direito, quer seja do elemento essencial à existência de todos os seres vivos.

Um bom exemplo é o que acabamos de ver nesta lição sobre as fases de desenvolvimento do Direito Comercial. Nós vimos que os estudiosos da matéria – responsáveis por criar a doutrina, ou seja, a palavra dos especialistas sobre o assunto – elaboraram teorias para explicar o fenômeno do comércio. Depois que essas teorias se tornavam famosas é que era feita a legislação para colocá-las em prática. Esse é um exemplo de uma fonte material (doutrina) influenciando na elaboração de uma fonte formal (lei).

O mesmo pode acontecer com a jurisprudência. Chama-se jurisprudência a decisão reiterada dos tribunais sobre um determinado tema. São os tribunais, através de seus juízes, os responsáveis por aplicar as leis. São eles que interpretam as normas jurídicas e as coloca em prática. Porém, as leis podem apresentar falhas, chamadas lacunas, as quais serão preenchidas pelos julgadores que, a cada decisão, buscam

colocar em prática o que a lei quis dizer. Pode ser que, no futuro, o legislador perceba a falha e resolva completá-la. Assim, através da atividade legislativa, edita-se a lei, ou faz-se uma nova, de acordo com o entendimento dos tribunais. Nesse caso, a jurisprudência – fonte material – influenciou na alteração da lei – fonte formal.

Para nós, importa conhecer as principais fontes formais específicas do Direito Empresarial, para que você saiba onde recorrer para sanar suas dúvidas sobre algum tema específico correlacionado à atividade empresarial.

Como vimos, o Direito Empresarial abrange um mundo de atividades das mais diversas formas e áreas. Por isso, existem muitas leis esparsas tratando do assunto. Chamamos de leis esparsas aquelas que não são codificadas, ou seja, que não estão reunidas dentro de um Código. Por exemplo: nós temos o Código Civil que reúne as principais regras aplicáveis às relações civis, mas temos também uma infinidade de leis fora do Código que também regulamentam essas relações.

O Direito Empresarial está presente na Constituição Federal (CF/88), no Código Civil de 2002 (CC/2002), no Código Comercial de 1850, bem como nos tratados e convenções de Direito Internacional, além de uma série de leis esparsas. Podemos citar a Lei das Sociedades Anônimas, o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, a Lei das Letras de Câmbio e Notas Promissórias, a Lei do Cheque, a Lei das Duplicatas, a Lei do Contrato de Concessão Mercantil para Veículos Automotores, a Lei de Locações, a Lei de Falências e Recuperação Judicial (CHAGAS, 2017, p. 64).

É importante ressaltar que, com o advento do Código Civil de 2002, revogou-se a primeira parte do Código Comercial de 1850 (comércio em geral), permanecendo em vigor a segunda parte, que regulamenta o comércio marítimo. Outra importante alteração no Direito Empresarial foi a revogação da antiga legislação falimentar, Decreto-lei n. 7.661/1945, não pelo Código Civil, mas pela Lei de Falências e Recuperação Judicial, Lei 11.101, promulgada no ano de 2005.

Além disso, há diversas recomendações e códigos de ética de determinadas categorias empresariais, as quais poderíamos chamar de “corporações de ofício pós-modernas” (CHAGAS, 2017, p. 63). Isso porque, um ramo empresarial difere muito de outro ramo, havendo mesmo a necessidade de se estabelecerem regras específicas para cada um deles.



Pense na área empresarial relacionada ao seu curso. Quais as peculiaridades presentes nela? Será que uma fábrica de cosméticos possui as mesmas necessidades que uma empresa desenvolvedora de softwares? O regramento aplicável a um grande empreendimento de engenharia possuiria utilidade para uma clínica veterinária ou um restaurante?

É em virtude dessas peculiaridades presentes nas mais variadas atividades empresariais que diversos nichos de mercado criaram seus próprios conselhos e associações, os quais estabeleceram códigos e recomendações aplicáveis especificamente àquele ramo. Como exemplo, podemos citar o CONAR (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária), a FEBRABAN (Federação Brasileira dos Bancos), a ABECS (Associação Brasileira de Estabelecimentos de Cartão de Crédito e Serviços), a ANFAC (Associação Nacional de Fomento Mercantil), a ABRASCE (Associação Brasileira de Shopping Centers) e a ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais), como nos lembra Chagas (2017, p. 63).

Por fim, é importante mencionar que há uma hierarquia entre as normas decorrentes das fontes formais de Direito. A Constituição será sempre a norma que ocupará o topo desta hierarquia, vindo abaixo dela as leis e, abaixo das leis, os decretos e

regulamentos dos poderes Executivo e Legislativo. Abaixo desses, encontram-se os códigos de ética e recomendações das associações, quando não decorrerem de atividade legislativa, ou seja, quando forem elaborados apenas no âmbito interno de cada associação.

Esta ordem hierárquica é geralmente representada pela famosa pirâmide normativa de Hans Kelsen:

Agora que você já sabe quais são os principais diplomas normativos aplicáveis ao Direito Empresarial, vamos falar sobre o sujeito mais importante desse ramo jurídico: o empresário.

5. Empresário: conceito e requisitos formais de regularidade

Já vimos que a Teoria da Empresa, a mais moderna e adotada atualmente, ocupa-se

dos vários perfis da empresa. Um deles é o perfil subjetivo, ou seja, a(s) pessoa(s) que desenvolvem a atividade empresarial.

Segundo o art. 966 do Código Civil:

> *Art. 966. Considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção ou a circulação de bens ou de serviços.*
>
> *Parágrafo único. Não se considera empresário quem exerce profissão intelectual, de natureza científica, literária ou artística, ainda com o concurso de auxiliares ou colaboradores, salvo se o exercício da profissão constituir elemento de empresa.*
> *(BRASIL, 2002)*

O empresário é, portanto, o sujeito que organiza a atividade empresarial de modo profissional. Por sua vez, atividade empresarial é a atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens e serviços. Podemos resumir dizendo que o empresário é quem exerce a empresa.

Do art. 966 do CC/2002 são extraídos, portanto, os dois requisitos necessários à caracterização do empresário. É preciso que ele **organize** a atividade empresarial e que o faça de modo **profissional**.

Com isso, podemos estabelecer a diferença entre empresário e empreendedor. Comumente, costumamos tratar as duas denominações como sinônimas, mas se trata de incorreção técnica.

O empresário é a pessoa que tem como profissão organizar a atividade empresária. Ele está rotineiramente ligado a tal atividade. O empreendedor pode apenas investir recursos nesta atividade ou participar esporadicamente das decisões. Sendo assim, ser sócio de uma sociedade empresária não faz daquela pessoa um empresário, ser investidor no mercado de ações também não, nem tampouco ser o representante de

jogadores de futebol ou de artistas, como comumente denominamos.

Tradicionalmente, associamos a expressão empresário à pessoa de negócios, envolvida nas grandes corporações. Mas, como veremos, o conceito de empresário não se limita a esse conceito tradicional.

Ainda que uma pessoa seja a proprietária ou sócia majoritária de um grande investimento, pode ela não ser considerada empresária. Vamos pensar no exemplo do apresentador de TV, Silvio Santos. É sabido que o canal de televisão SBT pertence a ele e à sua família. No entanto, ainda que ele seja o dono do empreendimento, isso não faz dele empresário. Por que? Porque, atualmente, o apresentador não organiza profissionalmente a atividade empresária. Ainda que, esporadicamente, ele participe das decisões sobre o empreendimento, ele tem pessoas que atuam profissionalmente na organização da empresa – os administradores. São essas pessoas que serão consideradas empresárias.

Nas sociedades empresariais, são considerados empresários os administradores da empresa e a própria pessoa jurídica, pois é ela quem aparece nos contratos, contraindo direitos e obrigações. Ainda que se trate de uma ficção jurídica, na medida

em que não existe no mundo real, a pessoa jurídica é sujeito de direitos e deveres e é considerada empresária.

Pode-se exercer a empresa (usada aqui no sentido técnico da palavra, enquanto sinônimo de atividade empresarial) em sociedade ou individualmente. Sendo assim, atualmente, temos três tipos de empresários:

- Empresário individual
- EIRELI
- Sociedades empresárias

As duas primeiras formas estão relacionadas ao exercício da empresa por uma única pessoa física. Essa pessoa, desde que cumpridos determinados requisitos, pode optar por exercer sua atividade registrando-se como **empresário individual** ou como **empresa individual de responsabilidade limitada – EIRELI**. Qual a diferença?

O empresário individual não goza do privilégio de distinguir seu patrimônio particular do patrimônio do empreendimento empresarial. Isto é, se o empresário individual tem uma dívida decorrente da atividade empresária, poderá responder por ela com seu patrimônio particular. Igualmente, se este empresário tiver uma dívida particular, poderá responder por ela com o patrimônio decorrente do empreendimento.



Imagine o seguinte exemplo: dona Maria registrou-se com empresária individual e iniciou um empreendimento de produção e venda de bolos. Ela organiza a atividade de modo profissional, mas, para dedicar-se ao empreendimento, precisou contratar uma empregada doméstica para sua

residência. Depois de alguns meses, Dona Maria deixa de pagar sua funcionária, que aciona a Justiça do Trabalho, a fim de receber pelo serviço prestado. Dona Maria não tem bens em seu nome para arcar com a obrigação, mas o negócio de produção e venda de bolos vai de vento em popa! A funcionária pode demandar que o pagamento de suas verbas seja feito com o lucro oriundo da atividade empresarial, pois não há distinção de bens para o empresário individual.

Por outro lado, o empresário que se registrar com EIRELI poderá manter as obrigações decorrentes de seu empreendimento empresarial separadas de seu patrimônio particular. Essa figura é relativamente recente em nosso ordenamento jurídico, tendo sido regulamentada através da Lei 12441 de 2011.

As principais diferenças entre o empresário individual e a EIRELI são as seguintes: em primeiro lugar, como dito, os patrimônios são separados, o patrimônio particular não responde pelo empreendimento; outra distinção é que, na EIRELI, cria-se uma pessoa jurídica e é por isso que há a possibilidade de se proteger o patrimônio particular do empresário. Contudo, não são todos os empresários que podem constituir uma EIRELI, sendo necessário o investimento mínimo de R$100.000,00 (cem mil reais), ou seja, o capital social da EIRELI tem que ter, no mínimo, esse valor.

As sociedades empresárias são formas de se exercer a atividade empresarial muito mais complexas do que o empresário individual e a EIRELI. Por isso, são assuntos para uma outra lição.

Concentremos nos requisitos para que uma pessoa seja considerada empresário.

Já vimos que, segundo o art. 966, empresário é aquele que organiza a atividade empresarial, exercendo-a de forma profissional. O art. 967, também do Código Civil,

estabelece que o empresário deve se registrar na Junta Comercial antes de iniciar suas atividades. Podemos dizer, portanto, que, se o art. 966 traz o conceito material de empresário, o art. 967 traz o seu conceito formal.

O art. 966 diz o que a pessoa precisa fazer, enquanto atividade, para que seja considerada empresária. Já o art. 967 diz qual o trâmite que ela deve seguir para alcançar esse status. Sendo assim, para que a pessoa seja formalmente considerada empresária, ela deve registrar-se como tal na Junta Comercial da sede do empreendimento.

> *Art. 967. É obrigatória a inscrição do empresário no Registro Público de Empresas Mercantis da respectiva sede, antes do início de sua atividade.*
>
> *(BRASIL, 2002)*

Mas, e se a pessoa desenvolve a atividade empresarial e não se registra? Ela não será considerada empresária? A resposta é: Sim, será considerada empresária! Aquele que deixa de realizar o registro necessário atua na informalidade, atua de modo irregular. Logo, empresário irregular.

O art. 968 do CC/2002 enumera o que deve conter no requerimento apresentado na Junta Comercial, mas é importante mencionar que, para que tal requerimento seja deferido, além de atender ao que preceitua o art. 968, o empresário deve respeitar, também, o art. 972 do CC/2002. Segundo esse artigo, apenas pode se registrar como empresário quem possui capacidade civil e não possui nenhum impedimento legal.

A ausência de impedimento legal é requisito negativo para o registro, ou seja, não pode existir para que o empresário consiga se registrar. A lei proíbe determinadas pessoas de exercer atividade empresária (juízes, promotores, chefe do Executivo e diversos outros servidores públicos), pessoas que participaram de atividade empresária e falharam (falência, dívidas no INSS, etc.). São essas pessoas que são consideradas impedidas de exercer a atividade empresarial. Vale ressaltar que, caso

os impedidos desobedeçam às restrições e se inscrevam, eles responderão pelas obrigações contraídas (art. 973 do CC/2002).

O segundo requisito é a capacidade civil. Não podem se registrar como empresários os menores de idade, os portadores de deficiência mental, os interditados, isto é, os incapazes civilmente. Todavia, poderão os incapazes continuar a atividade empresarial, em caso de herdarem a atividade ou de incapacidade superveniente.

Então, os filhos menores do empresário falecido podem prosseguir com a atividade, desde que devidamente representados ou assistidos. Da mesma forma, o empresário que se tornar incapaz poderá prosseguir com sua atividade através de seu assistente.

6. Conclusão

Chegamos ao fim da lição. Esperamos que você tenha sido capaz de compreender o trajeto do Direito Comercial até o Direito Empresarial, como esse ramo do Direito se desenvolveu em paralelo ao desenvolvimento do comércio e da Economia.

Esperamos, ainda, que você tenha apreendido os conceitos da Teoria dos Atos de Comércio, tenha entendido a necessidade de se superar tal teoria e compreendido por que a Teoria da Empresa é a mais adequada ao atual cenário de desenvolvimento das relações negociais.

Por fim, almejamos que você tenha entendido os critérios caracterizadores do empresário, as diferentes formas de se exercer a empresa e os seus respectivos requisitos formais de regularidade.

Até a próxima! Bons estudos!

7. Referência

BRASIL. Decreto n. 737, de 25 de novembro de 1850. Determina a ordem do Juizo no Processo Commercial. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/historicos/dim/DIM0737.htm

BRASIL. Lei n. 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10406compilada.htm.

CHAGAS, Edilson Enedino das. Direito Empresarial Esquematizado. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

COELHO, Fábio Ulhoa. Manual de Direito Comercial: Direito de Empresa. 28. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.

DANA, Samy. Ronald Coase, Nobel de Economia em 1991; conheça seu legado. Blog do Samy Dana. G1, 2017. Disponível em: http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/ronald-coase-nobel-de-economia-em-1991-conheca-seu-legado.html

MAMEDE, Gladston. Direito Empresarial Brasileiro: Empresa e atuação empresarial. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2019.

PERSECHINI, Silvia Ferreira. Teoria da Firma: uma relação entre a empresa e o mercado. Migalhas, 2009. Disponível em: https://www.migalhas.com.br/depeso/82885/teoria-da-firma-uma-relacao-entre-a-empresa-e-o-mercado

YouTube. (2019). Canal do Por Quê?. O Legado De Ronald Coase | Fala, Dudu! #17. 13min03. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=N61CNxBH68w&t.

Parabéns, esta aula foi concluída!

O que achou do conteúdo estudado?



Péssimo Ruim Normal Bom Excelente

Deixe aqui seu comentário

Mínimo de caracteres: 0/150

Enviar